

0009015-63.2015.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... foi detido por causa da acusação falsa de tráfico. Confirma que foi preso com Vanderlei por tráfico, tendo sido absolvidos.

A condenação criminal exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o delito e sua autoria, não bastando, para tanto, a alta probabilidade daquele ou desta. A certeza não pode ser subjetiva, formada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0009015-63.2015.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009015-63.2015.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 263/2015 - Delegacia de Polícia de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderlei Luciano da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VANDERLEI LUCIANO DA SILVA e RAFAEL APARECIDO JACOMASSI FROSINI, pela conduta prevista no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas em 25 de setembro de 2014.

Narra a denúncia que os réus, agindo em concurso e unidade de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, o veículo FIAT/FIORINO, placas EUM 4808 - Hortolândia - SP; um aparelho celular marca NOKIA; e 7 caixas de mercadorias da marca De Millus, pertencentes à vítima Renato Ferreira.

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 139/145 e apensos 01 e 02.

A denúncia foi recebida em 09/11/2017 (fls. 146/148).

Os réus foram citados (fls. 176;204) e apresentaram resposta escrita (fls. 153/161;190/194;208/209).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 214/216).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e

juízo, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus. Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelas peças do inquérito policial, destacando-se a Portaria (fls. 2), o Boletim de Ocorrência (fls. 4/5), e os autos de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 8/9); bem como pelos depoimentos (fls. 10/11), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto à autoria, a imputação contra os réus está assentada exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima.

Ouvido em juízo, a vítima Renato informou que, no dia dos fatos, estava no acesso à rua Joana D'Arc em Hortolândia, aguardando para entrar na rua, quando viu um Kadett branco, de capô preto, parando em sua frente, bloqueando a passagem, havendo quatro pessoas no interior. Nesse momento, um dos indivíduos desceu o vidro do passageiro, apontou uma arma para a ele e falou que tinha "perdido"; logo em seguida, dois indivíduos desceram do Kadett, fazendo-o descer do seu veículo e entrar no automóvel deles. Ao adentrar no carro, viu mais uma pessoa encapuzada com a blusa de frio que vestia. Declarou, ainda, que os dois homens que o fizeram descer estavam com blusa de frio, só sabe que era uma cor escura. Já no interior do Kadett, o motorista lhe assegurou que só estavam fazendo uma "fita", que o veículo seria abandonado depois. Os dois indivíduos identificados como Rafael e Vanderlei foram na frente com o carro da vítima, uma Fiorino de placas EUM-4808; a vítima seguiu no Kadett logo atrás deles; não conseguiu reconhecer o motorista. Fizeram o percurso dessa forma até a empresa Gonvarri, onde foi abandonado, cerca de 10/15 minutos após, distante 5 KM; levaram seus itens pessoais. disseram que o carro seria localizado depois. O declarante usou um orelhão, do outro lado da linha do trem, para o lado de Sumaré, a fim de acionar a polícia. Relata que, alguns dias depois, estava assistindo TV em sua residência quando viu no jornal uma matéria, tendo reconhecido os dois indivíduos que o roubaram e viu que eles tinham sido presos em Campinas. O declarante compareceu à delegacia e fez o reconhecimento fotográfico dos réus, confirmando, com certeza, que se tratava de dois dos autores do roubo de que foi vítima.

Esclareceu que um deles tinha uma cicatriz bem marcante no rosto, tendo o visto em uma reportagem televisiva; fez o reconhecimento por fotografia; o outro era um rapaz moreno; os outros dois não se recorda; o reconhecimento não foi muito após o assalto, então pode reconhecer sem dúvida. Dois estavam armados, sendo que um deles ficou com a arma na altura da sua cintura durante o percurso. Recuperou o carro em Monte Mor alguns meses após e estava com algumas adulterações, com mudança de placa. O rapaz da cicatriz era branco, sendo os demais pardos. O veículo teria sido apreendido com duas pessoas. Os réus não estavam na delegacia. Lhe apresentaram 4 fotos, sendo que o rapaz com a cicatriz pode reconhecer bem. Esse rapaz foi o mesmo que viu na televisão. Foi o moreno quem o rendeu, o colocou no outro carro, sentou-se no banco de trás e retirou-lhe os pertences. Indago sobre a cor das pessoas afirmou que um era bem moreno e os outros três "eram mais parecidos para branco", sendo que o com cicatriz era bem branco. Foi-lhe exibido 4 fotografias dos réus, sendo que por uma delas pode identificar bem a pessoa com a cicatriz.

Colhe-se, assim, do depoimento e dos termos de fls. 8 e 9 que se tratou de reconhecimento exclusivamente fotográfico, após comparecimento da vítima em delegacia 5 dias após o crime, motivado por reportagem televisiva que exibiu os réus detidos por suspeita da prática de outro delito. A vítima esclareceu que durante o reconhecimento fotográfico lhe foram exibidas fotografias apenas das pessoas dos réus.

As circunstâncias da apresentação espontânea da vítima para reconhecimento exigiam da autoridade policial maior rigor na realização do ato, notadamente o cumprimento do art. 226 do CPP. Exigia, inclusive, que se procedesse ao reconhecimento pessoal, o que não foi feito em nenhuma oportunidade, muito embora os réus estivessem custodiados por conta de outro fato, pelo qual, frise-se, foram

absolvidos.

Contrariamente, a vítima compareceu na delegacia em 30/10/2014, sendo que os réus somente foram ouvidos em 07/07/2017 (f. 104 e 113), sem a realização de nenhuma outra diligência policial no intervalo, limitando-se, portanto, a autoridade policial àquele reconhecimento fotográfico.

A vítima relatou que lhe foram apresentadas 4 fotografias dos réus, entretanto a autoridade policial não as registrou no inquérito policial, o que impede qualquer confrontação.

Ademais, a vítima relatou sobre a cicatriz da pessoa que seria o réu Vanderlei, ocorre que a autoridade policial não fez nenhum registro a respeito. E passados tantos anos a fotografia atual de fls. 331/333 não exhibe nenhuma cicatriz.

Por sua vez, o reconhecimento do réu Rafael baseia-se exclusivamente no seu tom de pele e por estar na companhia de Vanderlei na emissão televisiva.

A propósito, quando lavrou o BO a vítima relatou que eram "elementos negros e um branco" (sic) e "não soube passar mais informações sobre os elementos" (sic).

Quando indagado em Juízo teve dificuldade de precisar, narrando que um era bem moreno e os outros três "eram mais parecidos para branco", sendo que o com cicatriz era bem branco.

Tem-se, ainda, a informação pela vítima de que lhe foram exibidas 4 fotografias dos réus, sendo que por apenas uma delas pode identificar a pessoa com a cicatriz, não sendo específico em relação ao réu Rafael.

Por essas circunstâncias, tenho que a condenação amparada exclusivamente no reconhecimento fotográfico nos moles em que realizado, não autoriza a condenação, notadamente diante da ausência de qualquer outro indício.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que se formou sobre o art. 226 do CPP é no sentido de não se admitir a prova da autoria "exclusivamente" com base no reconhecimento realizado apenas no modo fotográfico ou presencialmente sem as cautelas do art. 226 do CPP, cumprindo ao Juiz a análise conjunta de toda a prova produzida.

É o que se extrai do paradigmático HC 598886 / SC, no qual se assentou que:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais,

já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido

procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

As demais provas produzidas em nada permitem a confirmação da autoria.

A testemunha de defesa Felipe Leandro dos Santos Moreno disse em juízo que tem uma barbearia ao lado do comércio de Vanderlei; sempre o via abrindo ou fechando o bar logo cedo, a depender se trabalhava de madrugada; não via pessoas estranhas no local; conhece Rafael também, já o tendo visto várias vezes no bar de Vanderlei; ele mora no mesmo bairro.

Em interrogatório, o réu Vanderlei Luciano da Silva disse que conhece Rafael do bar que tinha, sendo ele frequentador; não tem mais o comércio; soube do roubo apenas quando foi ouvido na Depol; não tem Kadett branco e não sabe se Rafael tem; não tem cicatriz no rosto; foi preso em 26 de setembro de 2014 e, de fato, teve suas imagens divulgadas pela imprensa. Relatou que Rafael também foi preso pela mesma acusação falsa de tráfico.

Interrogado em juízo, o réu Rafael Aparecido Jacomassi Frosini negou a prática do crime. Relatou que, no dia dos fatos, estava trabalhando como motoboy na pizzaria do Mineiro. Disse que não conhece a pessoa do réu Vanderlei, acreditando ser o possível dono do bar onde foi detido por causa da acusação falsa de tráfico. Confirma que foi preso com Vanderlei por tráfico, tendo sido absolvidos.

A condenação criminal exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o delito e sua autoria, não bastando, para tanto, a alta probabilidade daquele ou desta. A certeza não pode ser subjetiva, formada pela consciência do julgador, de modo que, diante da incerteza dos fatos, deve-se inclinar sempre em favor da absolvição, em estrita observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Diante disso, se o conjunto probatório não se mostra seguro, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO VANDERLEI LUCIANO DA SILVA, RG: 41.327.406-8, e RAFAEL APARECIDO JACOMASSI FROSINI, RG: 37.315.549-9, da imputação que lhe é feita na denúncia por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se certidão nos termos do Convênio OAB/DPE.

Publique-se. Intimem-se. Cumram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA